

SENTENCIA NÚMERO: 169

En la ciudad de Córdoba, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho, se reunieron en Acuerdo Público los Sres. Vocales de la Cámara de Apelaciones de Primera Nominación en lo Civil y Comercial, Dres. Julio C. Sánchez Torres, Guillermo P. B. Tinti y Leonardo C. González Zamar a los fines de dictar sentencia en los autos caratulados “**REYNA, CAROLINA C/ SEGUROS RIVADAVIA COOPERATIVA LIMITADA – ORDINARIO – COBRO DE PESOS**” – EXPTE. N° **6158307**, venidos con fecha 01.08.18 del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Trigésima Nominación, con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia número ciento setenta y cuatro de fecha diecinueve de junio de dos mil dieciocho (cfr. fs. 302/310), dictada por la Sra. Juez Dra. Ilse Ellerman, **que resolvía:** “*I.- Rechazar en todas sus partes la demanda promovida por la Sra. Carolina REYNA DNI 26.481.760, en contra de SEGUROS RIVADAVIA COOPERATIVA LIMITADA. --- II.- Imponer las costas a la actora vencida. --- III.- Regular los honorarios profesionales definitivos de los Dres. Julio Isidro Altamira Gigena y Carolina Altamira - abogados del actor- en la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$38.499, 44), en conjunto y proporción de ley. Asimismo, regulo la suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON DIECISEIS CENTAVOS (\$ 2. 237,16) en razón del art. 104 inc. 5° de la ley 9459, también en conjunto y proporción de ley. De igual modo, corresponde regular la suma de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$8.554 ,69), en concepto de IVA sobre honorarios. --- IV.- Regular los honorarios profesionales definitivos del Dr. Agustín Gorrochateui –abogado apoderado de la demandada - en la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON DIECINUEVE CENTAVOS (\$ 192.497,19), con más la suma de PESOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON CUARENTA CENTAVOS (\$40.424,40) en concepto de IVA. Protocolícese... ”.*

Este Tribunal en presencia de la Actuaría se planteó las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Puede el recurso de apelación planteado por la parte actora?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

Efectuado el sorteo de ley resultó que los Sres. Vocales emitirán sus votos en el siguiente orden: Guillermo P. B. Tinti, Leonardo C. González Zamar y Julio C. Sánchez Torres.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR VOCAL DR. GUILLERMO P. B. TINTI, DIJO:

I.- En contra de la sentencia relacionada, cuya parte resolutive ha sido transcripta, la parte actora dedujo recurso de apelación, el que fue concedido a fs. 312.

Radicada la causa en esta Sede e impreso el trámite de ley, la apelante expresó sus agravios (cfr. fs. 322/334), los que fueron contestados por la parte demandada (cfr. fs. 337/353).

A fs. 356/359 vta. luce incorporado el dictamen emitido por la Sra. Fiscal de Cámara.

Dictado y firme el decreto de autos, quedó el recurso en condiciones de estudio y resolución.

II.- La sentencia apelada contiene una adecuada relación de causa que satisface las exigencias del art. 329 del CPCC, por lo que a ella me remito.

III.- En cuanto ahora interesa, cabe ponderar que la Sra. Carolina Reyna promovió demanda en contra de “SEGUROS RIVADAVIA”, persiguiendo el cobro de la suma de pesos cuatrocientos mil (\$400. 000), o lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse en autos, con más sus intereses hasta el día de su efectivo pago, y las costas del juicio, en concepto de indemnización del daño patrimonial y moral sufrido a causa de haber resultado víctima de un accidente de tránsito ocurrido el día diez de noviembre de dos mil quince (10/11/2015). Relató que en la mencionada fecha, cuando salía de efectuar

compras en “Tadicor”, ingresó a la calle Monseñor Pablo Cabrera a la altura de la Estación de Servicios “El Gran “Vidrio”; y mientras el tráfico se encontraba detenido en la subida del puente, fue embestida de atrás por un colectivo FONO BUS, dominio KVO852, conducido por el Sr. Sergio Meisel. Agrega que realizó la denuncia del siniestro ante la compañía aseguradora del vehículo FONOBUS, “Seguros Rivadavia” y ante el fracaso de las gestiones extrajudiciales inicio el presente proceso (cfr. fs. 1/10).

La demandada SEGUROS RIVADAVIA evacuó el traslado de la demanda, planteando la improponibilidad objetiva de la pretensión incoada y la falta de acción de la actora para demandar directamente a la aseguradora. Subsidiariamente, contestó la demanda, negando en general y en particular todos los hechos y el derecho invocado por la actora, y la existencia y cuantía de los daños reclamados e impugnando la documental presentada (cfr. fs. 99/111).

El tribunal de primera instancia rechazó la demanda e impuso las costas a la actora, en virtud de considerar que esta última carecía de una acción directa en c ontra de la compañía aseguradora a tenor de lo dispuesto por el art. 118 de la ley de seguros N° 17.418 y como no había demandado también al sujeto asegurado, se verificaba la ausencia de un presupuesto esencial para poder extenderle la eventual condena a la empresa.

IV.- En contra de la sentencia de grado se alza en apelación la actora (cfr. fs. 322/334).

En primer término, arguye que la Iudex rechazó la demanda sin considerar las constancias de autos que preceden la resolución, y con ello transgredió el principio de preclusión, seguridad jurídica y el debido proceso que hace al derecho de defensa (art. 18 de la CN).

Sostiene que en esta litis, se ha aceptado la proponibilidad objetiva de la demanda, en base a los proveídos de fecha 28 /07/ 16 (fs. 89) y 14/0 9/16 (fs.114), por medio de los cuales se imprimió a trámite de proceso ordinario a este juicio y se rechazó el planteo de improponibilidad, respectivamente. Que dichos proveídos se encontraban firmes y consentidos, habiéndose producido la preclusión procesal con los efectos propios de la cosa juzgada formal. Afirma que al haber consentido la demandada el rechazo de su planteo de improponibilidad objetiva de la demanda, no se podía volver sobre esa cuestión, de manera que lo único que correspondía analizar en la sentencia, era si se encontraba acreditada la relación de causalidad entre los daños denunciados y el accidente provocado por su asegurado.

En segundo lugar, se queja porque el tribunal aquo no dio trascendencia jurídica al ofrecimiento realizado por la Compañía de Seguros a la actora en concepto de indemnización, en dos oportunidades, y que ese ofrecimiento se hizo en nombre propio, no en representación de Fono Bus. Que allí reconoció la deuda y ofreció cancelarla, y al momento de contestar la demanda lo negó, y que ello vulnera la teoría de los propios actos. Invoca en este punto lo normado por el art. 1067 del Código Civil y Comercial de la Nación, sosteniendo que la parte demandada ha violado el principio de confianza legítima.

En tercer lugar, reprocha que no se aplicaran los principios establecidos en el nuevo ordenamiento fondal (arts. 1092 y 1096), el art. 68 de la ley Nacional de Tránsito y la ley de defensa del Consumidor.

Asevera que en función a la normativa citada el beneficiario directo de un contrato de seguro obligatorio es la “víctima” del siniestro, que ello no ha sido considerado en la sentencia impugnada.

Arguye que conforme el espíritu del nuevo Código Civil y Comercial se incorporó como consumidor a la víctima de un accidente de tránsito, y que da la posibilidad de demandar directamente a la Compañía Aseguradora intentando la reparación de su perjuicio.

Agrega que en la sentencia de primera instancia se omite también considerar los arts. 1, 2, 1067, 1094, 1095, 1096 y concordantes del CCyCN.

Por último, se agravia de la imposición de costas a su cargo. Aduce que existió

mérito para eximir a la actora de la condena en costas, porque no había duda alguna que la Compañía de Seguros asumió extrajudicialmente su responsabilidad en virtud de las pruebas aportadas en la actuación administrativa, y del ofrecimiento extrajudicial realizado.

Finalmente, solicita la intervención del Ministerio Público invocando la existencia de una relación de consumo en el caso de autos y que la citada en garantía se enmarca dentro del concepto de proveedor sentado por el art. 2 de la ley 24.240.

VI.- En forma preliminar, adelanto que corresponde desestimar el pedido de declaración de deserción recursiva formulado por la parte demandada.

En efecto, no obstante las salvedades que se puntualizaran a lo largo del presente voto, advierto que en general el escrito de expresión de agravios del actor reúne los elementos necesarios para tener por expresado su embate contra la sentencia apelada, por cuanto ha expuesto los motivos por los cuales pretende la reforma del decisorio, debiendo tenerse por cumplida la carga procesal de que se trata.

Sobre el punto, la doctrina ha dicho: “...se debe privilegiar la composición de la causa con justicia, antes que una fría legalidad, decidiendo el pleito de un modo real y profundo. Es por ello que se ha declarado que la brevedad o laconismo de la expresión de agravios no constituye razón suficiente para sentar la deserción del recurso en el supuesto que el apelante individualice, aún en mínima medida, los motivos de su disconformidad con la sentencia impugnada, por cuanto la gravedad de los efectos que la ley imputa a la insuficiencia del mencionado acto procesal aconseja aplicarla con criterio amplio, favorable a la admisibilidad del recurso” (Azpelicueta, Juan J. - Tessone, Alberto: *La Alzada, Poderes y Deberes*, Librería Editora Platense S. R. L. La Plata, 1993, p. 30).

En consecuencia, debe dirimirse en esta Sede si luce ajustada a Derecho la sentencia apelada en cuanto resolvió desestimar la demanda. Adelanto que mi respuesta es parcialmente favorable a la actora recurrente.

VII. 1- En tren de justificar el aserto precedente, comenzaré por señalar que el fin perseguido con el contrato de seguro se enrola entre los instrumentos que desarrollan funciones resarcitorias que tienden a recomponer el empobrecimiento que sufren los sujetos expuestos a riesgos, los que son cada vez más numerosos y complejos en la sociedad moderna (cfr. Stiglitz, Rubén S.: *Derecho de Seguros*, 6ª edic. act. y ampl., La Ley, 2016, t. I, p. 6).

El fin perseguido con el seguro es la traslación de un riesgo a un tercero, para que sus eventuales consecuencias graviten sobre éste, que lo asume mediante el pago de una prima o cotización, siempre que exista interés asegurable (arts. 1 y 2, ley 17.418) (Halperín, Isaac – Barbato Icolas H.: *Seguros*, LexisNexis Depalma, 2003, p. 51).

A su vez, toda persona debe reparar el daño que ha causado a otra (art. 19 CN), por medio de una indemnización o compensación económica, como consecuencia de la violación de un deber jurídico preexistente y determinado (responsabilidad contractual) o por la violación de un deber jurídico genérico e indeterminado -no causar daño a otro- (responsabilidad extracontractual). En el ordenamiento jurídico argentino ambas órbitas de la responsabilidad civil han sido unificadas en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (art. 1716 CCyCN), aunque subsisten diferencias irreductibles por la estructura de las diversas fuentes de la obligación de reparar el daño causado.

Entonces, a fin de evitar una lesión directa al patrimonio de quien ha provocado un daño, el seguro contra la responsabilidad civil permite a un sujeto (el “asegurado”) trasladar las consecuencias dañosas de un evento económicamente desfavorable a otro que es el asegurador, a cambio del pago de un precio.

En consecuencia, mediante el seguro contra la responsabilidad civil se cubren los daños que el asegurado ocasiona a terceros en las condiciones y límites asumidos. En algunos casos se impone la contratación obligatoria de un seguro y en otros resulta facultativa.

La finalidad resarcitoria del contrato de seguro en general se desprende del art. 1º

de la ley de 17.418 en cuanto le impone al asegurador: la obligación de *“resarcir un daño o cumplir la prestación convenida si ocurre el evento previsto”* y, con relación al seguro contra la responsabilidad civil, en su art. 109 en cuanto obliga al asegurador *“a mantener indemne al asegurado por cuanto deba a un tercero en razón de la responsabilidad prevista en el contrato”*.

De tal forma, el seguro contra la responsabilidad civil resulta contratado por el eventual responsable del daño causado, es decir, el asegurado, en su propio interés, y no en interés del tercero damnificado. Tiene por objeto la protección del patrimonio del asegurado, ya que la causa fin del contrato es la eliminación del daño que sobreviene a éste por el nacimiento de una deuda de responsabilidad civil, sea ésta contractual o extracontractual, y porque quien se asegura es quien tiene a riesgo su patrimonio amenazado por la posibilidad de una reducción derivada de tener que hacer frente al eventual reclamo de un tercero (cfr. Stiglitz, Rubén S.: *Derecho de Seguros*, 6ª edic. act. y ampl., La Ley, 2016, t. IV, pp. 68 y ss.).

La obligación asumida por el asegurador es autónoma respecto de la que tiene el asegurado con el tercero, que tiene su origen en la relación sustancial de responsabilidad.

En ese andarivel, haciendo suyo el dictamen del Procurador General, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que *“el damnificado es acreedor del autor directo, situación que no se altera por la circunstancia de que se haya tomado un seguro que ampare el riesgo en los términos del art. 109, ley 17418, toda vez que se trata de obligaciones concurrentes o in solidum. Por ello, en los casos en que la condena de daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito se hace extensiva a la citada en garantía (art. 118), no debe confundirse la responsabilidad que le corresponde a ésta en virtud de la relación contractual que la vincula al asegurado demandado -cuyo patrimonio se obliga a mantener indemne en la medida, las condiciones y los límites del respectivo contrato de seguro-, con la que se atribuye al causante del hecho ilícito, de carácter extracontractual”* (CSJN, “Ávalos, Hugo M. v. Czumadewski, Alejandro”, 11/07/2007, LL Online, cita: 35011294). En la misma línea se señaló que *“la relación obligacional legal que vincula a la víctima con la aseguradora es independiente de aquella que se entabla entre ésta y el asegurado, enlazadas únicamente por el sistema instituido por la ley 17.418 (art. 118 citado). Ambas obligaciones poseen distintos sujetos -no son los mismos acreedores y los deudores en una y otra obligación -, tienen distinta causa - en una la ley, en la otra el contrato- y, demás, distinto objeto - en una la de reparar el daño, en la otra garantizar la indemnidad del asegurado -, en la medida del seguro”* (CSJN, “Flores, Lorena R. c. Giménez, Marcelino O. y otros/ daños y perjuicios (acc. trán. c/ les. o muerte)”, 06/ 06/ 2017, voto de los Dres. Lorenzetti y Highton de Nolasco, Cons. 12º).

Y bien, la obligación de indemnidad que asume el asegurador es sólo a favor del asegurado y no del tercero damnificado, no pudiendo éste invocar el contrato en su favor (art. 1022 CCyCN).

A este último la ley le otorga un privilegio sobre la suma asegurada en caso de concurso o quiebra del asegurado y, sobre todo, le reconoce la posibilidad de solicitar la citación en garantía del asegurador, al proceso que haya entablado contra el responsable del daño y lograr que se le extiendan a aquél los efectos adversos de la eventual sentencia condenatoria dictada contra el asegurado.

En efecto, el art. 118 de la ley 17.418 prescribe: *“El crédito del damnificado tiene privilegio sobre la suma asegurada y sus accesorios, con preferencia sobre el asegurado y cualquier acreedor de éste, aun en caso de quiebra o de concurso civil. El damnificado puede citar en garantía al asegurador hasta que se reciba la causa a prueba. En tal caso debe interponer la demanda ante el juez del lugar del hecho o del domicilio del asegurador. La sentencia que se dicte hará cosa juzgada respecto del asegurador y será ejecutable contra él en la medida del seguro. En este juicio o en la ejecución de la sentencia el asegurador no podrá oponer las defensas nacidas después del siniestro. También el asegurado puede citar en garantía al asegurador en el mismo plazo y con*

idénticos efectos”.

Conocida es la polémica desarrollada en torno a la naturaleza jurídica que reviste la “citación en garantía” de la compañía aseguradora que menciona la norma cuando se refiere a su intervención en el proceso a instancia del tercero damnificado (cfr. por todos, Pizarro, Ramón D. – Vallespinos, Carlos G.: *Tratado de Obligaciones*, Rubinzal Culzoni, 2017, t. II, pp. 421/424).

Conforme a una opinión, la citación en garantía que consagra dicha norma no constituye técnicamente una acción directa contra el asegurador, sino un dispositivo legal con características propias. Desde esa óptica, el damnificado debe accionar contra el asegurado, sindicado como responsable, y sólo en tales circunstancias puede citar a juicio a la aseguradora. La citación en garantía otorga al asegurador una intervención obligada como tercero en la litis. En tal caso, la condena que se dicte contra el asegurado, causante del daño, hace cosa juzgada respecto del asegurador y es directamente ejecutable en su contra, en la medida del seguro.

De acuerdo a otra postura, la ley consagra una acción directa, aunque atípica, pues requiere que sea practicada en un proceso seguido contra el asegurado, y no de manera autónoma. Tal circunstancia, si bien marca una anomalía, no desnaturaliza ría la institución, pues la sentencia a dictarse en el juicio hará cosa juzgada en contra de la aseguradora y será ejecutable, por ende, en contra de ella.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado “...*que al reconocer al damnificado la facultad de citar en garantía a la aseguradora del demandado y, como consecuencia, extender respecto de la citada los efectos de la cosa juzgada y establecer que la sentencia condenatoria será ejecutable contra dicha parte, el art. 118 de la ley 17.418 no se ha limitado a instituir un mero llamado a la causa del asegurador, sino que, con abstracción del nomen iuris utilizado, ha legitimado al actor para acumular a la pretensión deducida contra el responsable otro reclamo de idéntico objeto contra el asegurador (Fallos: 315: 698 y sus citas)...*” (CSJN, “La Holando Sudamericana Cía. de seguros en: Castillo de los Santos, Rodolfo c. Manferro S. A.”, 06/05/ 1997, Fallos: 320:827, LA LEY 1998-C-973).

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia tiene resuelto que “...*la ley de seguros no consagra una acción directa del damnificado contra el asegurador, pues obliga a aquél a dirigirla contra el asegurado y en su caso, contra el asegurador y no admite que la acción sea entablada sólo contra éste último. Ello significa que no puede ser condenado como demandado, pues la sentencia sólo hace cosa juzgada en su contra, la que será ejecutable, conforme los términos de la relación contractual...*” . Dicha conclusión, se asentó sobre la base de que “... *no existe disposición legal de carácter sustancial que acuerde a la víctima de un hecho una acción directa contra el asegurador del responsable civil -sólo la contenía el anteproyecto Halperín-. Ello es así, toda vez que si la normativa vigente hubiere querido conceder tal acción no hubiera tenido necesidad de aclarar que la sentencia hace ' cosa juzgada' respecto del asegurador. Ello ocurriría cuando la resolución quede firme y será a partir de ese momento cuando se ponga en movimiento el contrato de garantía y sus consecuencias...*” (TSJ, Sala CyC., “Morchio de García, Graciela E. y otros c/ Luciano Terenzio y otra -Ejecución de sentencia (sumas líquidas) Recurso de Casación”, Auto N° 173, 04/09/2002 ; reiterado en “Blanes Alba Nora c/ Dante Oscar Carrizo – Ordinario - Cpo de Copias – Apelación - Recurso de Casación”, Auto N° 307, 17/11/2008).

De todas formas, tal como se ha visto, cualquiera sea el temperamento que se adopte sobre el tópico, es incontrovertible que la ley 17.418 estatuye - *en el marco de su regulación* - un presupuesto de ineludible observancia para tornar operativa - a petición del tercero damnificado- la prestación a cargo de la aseguradora, como es la exigencia de deducir previa o simultáneamente la pretensión contra el sindicado responsable civil.

Tal requisito no fue satisfecho en autos, de modo que, *en el contexto normativo de la ley 17. 418*, la Sra. Carolina Reyna no podía demandar en forma directa y exclusiva a la aseguradora de la responsabilidad civil del presunto responsable del daño.

Por lo demás, ni la ley de Defensa del Consumidor ni el Código Civil y Comercial de la Nación, en las condiciones de su vigencia, condicionan en modo alguno esa conclusión, puesto que siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se trata de leyes generales posteriores que no derogan ni modifican implícita o tácitamente, una ley especial anterior, cuando dicha ley regula un régimen singular tal como ocurre en el caso de los contratos de seguro (CSJN, “Flores, Lorena R. c. Giménez, Marcelino O. y otros/ daños y perjuicios (acc. trán. c/ les. o muerte)”, 06/ 06/ 2017, voto de los Dres. Lorenzetti y Highton de Nolasco, Cons. 5º; voto del Dr. Rosenkratz, Cons. 14º).

VII. 1- Va de suyo que esa conclusión no se resiente por haber consentido la demandada la tramitación del presente juicio, toda vez que la legitimación sustancial de las partes remite a la necesidad de verificar, aun de oficio, que reúnan las cualidades emanada de la ley para requerir o soportar una sentencia de fondo respecto del objeto litigioso.

En ese sendero se inscribe también el pensamiento del Excmo. Tribunal Superior, al sostener que *“...la calidad o legitimación ad causam (entendida como la identidad entre las personas del actor o del demandado, y aquéllas especialmente habilitadas por la ley para asumir tales calidades) es un extremo que el juez debe examinar previamente al ingresar a la consideración de la pura sustancia del asunto, pues de faltar la misma ningún derecho a favor del actor (o, su caso, del demandado) podrá ser declarado. En otros términos – por regla- la ausencia de legitimación constituye un impedimento sustancial para que el magistrado pueda expedirse acerca de la existencia del derecho que se controvierte en el juicio, ya que representa un requisito de la pretensión contenida en la demanda, y no una excepción en sentido estricto ni un impedimento procesal. Así, la legitimación en la causa no es un presupuesto procesal, porque -lejos de referirse al procedimiento- contempla la relación que debe existir entre el sujeto demandante o demandado y el interés sustancial discutido en el proceso.... En otras palabras, el órgano judicial está habilitado para examinar la legitimación sustancial de las partes ‘ ex officio’, pues constituye un deber del magistrado verificar si, de acuerdo con las normas vigentes, quienes accionan o son demandados se encuentran autorizados para formular o controvertir la pretensión de que se trata”* (TSJ, Sala CyC., “Lusso Jorge Omar y otro - Recurso de Apelación - Expte. Interior (Civil) - Usucapión - Recurso de Casación - (Expte. L 13-12)”, N° 1883838/36, Sent. N° 89, 18/06/2014).

VII. 2- Advierto, por otro lado, que no asiste razón a la actora en cuanto afirma que la legitimación sustancial de ambas partes encuentra fundamento en la ley de defensa del consumidor, lo que la habilitaría a demandar a su elección al cualquiera de los integrantes de la relación de consumo.

Al respecto, yerra la apelante al sostener que en los “fundamentos” del que fuera el anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, los miembros de la comisión redactora habían afirmado que en el novel ordenamiento se establecía la figura del “consumidor expuesto” incluido en la ley de defensa del consumidor, de manera tal que se podría considerar consumidor al peatón víctima de un accidente de tránsito con relación al contrato de seguro celebrado entre el responsable civil y su aseguradora.

Antes al contrario, la ley 26 .994 - que aprobó el nuevo Código Civil y Comercial vigente- eliminó de la LCD la figura del “consumidor expuesto” que la ley 26.361 había incluido en su art. 1º (*“Se considera asimismo consumidor o usuario... a quien de cualquier manera está expuesto a una relación de consumo”*), reubicándola con un alcance acotado a las prácticas comerciales abusivas en su art. 1.096.

En este sentido, en los Fundamentos del Anteproyecto del Código Civil y Comercial de la Nación, sus autores los Dres. Lorenzetti, Highton de Nolasco y Kemelmajer de Carlucci, afirman: *“...En especial cabe mencionar la figura del “consumidor expuesto”, incluido en la ley especial dentro de la definición general de consumidor. Ello ha sido una traslación inadecuada del Código de Defensa del Consumidor de Brasil (artículo 29), que contempla esta noción en relación a las prácticas comerciales, pero no como noción*

general. Como se advierte, la fuente, si bien amplía la noción de consumidor, la limita a quien se halla expuesto a prácticas abusivas, lo que aparece como absolutamente razonable. En cambio, la redacción de la ley 26.361, carece de restricciones por lo que, su texto, interpretado literalmente, ha logrado una protección carente de sustancialidad y de límites por su amplitud. Un ejemplo de lo expuesto lo constituye el hecho que alguna opinión y algún fallo que lo recepta, con base en la frase ‘expuestas a una relación de consumo’, han considerado consumidor al peatón víctima de un accidente de tránsito, con relación al contrato de seguro celebrado entre el responsable civil y su asegurador. La definición que surge del texto constituye una propuesta de modificación de la ley especial. De todos modos, y tomando como fuente el artículo 29 del Código de Defensa del Consumidor de Brasil, la hemos reproducido al regular las ‘Prácticas abusivas’ toda vez que, en ese caso, su inclusión aparece como razonable”.

Pero aun colocándonos en la hipótesis más favorable a la recurrente para encuadrar su rol sustancial en el concepto general de consumidor al que se refieren los arts. 1.092 CCyCN y 1º LDC en tanto “*destinatario final*” de la indemnización reclamada, tesis cuando menos discutible -pues aun siendo imperativa la contratación de un seguro de responsabilidad civil, la obligación de la aseguradora fundada en la ley 17.418 continúa circumscripta a mantener indemne al asegurado, no a la víctima-, lo cierto es que la pretensión de la actora no engastaría en la norma del art. 40 del plexo consumeril para tornar viable la promoción de su demanda exclusivamente en contra de la compañía aseguradora.

Recuérdese que el art. 40 de la ley 24.240 edicta: “*Si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, responderán el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio. El transportista responderá por los daños ocasionados a la cosa con motivo o en ocasión del servicio. La responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan. Sólo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena*”.

En el caso sub iudice, el daño (patrimonial y moral) que alega la actora halla su causa generadora en un accidente de tránsito, esto es, no “*resulta de la prestación del servicio*” asegurativo que la demandada debe al asegurado, entre quienes sí existe un vínculo consumeril. De allí que la legitimación sustancial de las partes tampoco puede asentarse en la ley 24.240.

VII. 3.- A mayor abundamiento, el seguro de responsabilidad civil no es una estipulación a favor del tercero porque la víctima nunca se incorpora a la relación contractual establecida entre el asegurado y su aseguradora, si bien “*se beneficia*” cuando la aseguradora cumple con su obligación que consiste en mantener indemne el patrimonio del asegurado.

La doctrina especializada no ha dejado de remarcar las diferencias sustanciales entre el seguro contra la responsabilidad y la estipulación a favor de terceros:

a) El seguro contra la responsabilidad civil, es un contrato celebrado por cuenta y en favor del asegurado, por lo que no constituye una estipulación en favor de tercero. Por definición, es un contrato que celebra el asegurado, con la finalidad de que el asegurador lo mantenga indemne de cuanto deba pagar a un tercero en razón de la responsabilidad incurrida. El damnificado es un tercero ajeno al contrato de seguro, por lo que no ostenta condición de acreedor del asegurador, ni de beneficiario de una estipulación en su favor. En cambio, en la estipulación en favor de tercero, la ventaja constituida en favor de este último, se halla expresamente contenida en una regla de autonomía sustentada siempre en un texto legal y se eleva a categoría de causa-fin contractual.

b) El damnificado (tercero), es acreedor del responsable (autor directo o reflejo), de fuente contractual o extracontractual. Situación que no se altera por la circunstancia de que el agente del daño haya tomado un seguro que ampare el riesgo. Queremos decir, que la existencia de un asegurador, no le añade a la víctima un nuevo deudor (salvo el supuesto previsto por el art. 118 -3, L.S.), pues el primero sigue siendo obligado de su

único acreedor: el asegurado. En cambio, la estipulación en favor de un tercero, pone en evidencia un mecanismo por el cual el derecho del beneficiario es creado (nace) por un contrato celebrado entre otros, y recién desde entonces es acreedor bajo condición suspensiva negativa (que no se le revoque);

c) El objeto del crédito del damnificado es la reparación de un daño. El débito del responsable nace desde el momento mismo de la comisión del ilícito o desde que inejecuta la obligación. Por el contrario, el crédito del beneficiario ha sido estipulado en su favor con la finalidad, en ocasiones, de procurarle un provecho patrimonial que no computaba como propio, por ejemplo el seguro de vida o la donación con cargo, en ambos casos, en favor de un tercero;

d) En el seguro contra la responsabilidad civil, el crédito del damnificado contra el asegurado prospera total o parcialmente o es desestimado. Pero cuando nace (con el ilícito lato sensu), no requiere ser aceptado, y cuando es afirmado, por reconocimiento extrajudicial o por sentencia de condena, no es factible de ser revocado por el titular pasivo del débito. En cambio, la estipulación en favor de tercero, puede ser revocada mientras no haya sido aceptada;

e) En el seguro contra la responsabilidad civil, existe un único acreedor (invariable) al débito de responsabilidad: la víctima o sus causahabientes. La estipulación en favor de tercero tolera que, antes de ser aceptada pueda ser revocada, en cuyo caso puede designarse otro acreedor (el beneficiario o el propio estipulante);

f) El seguro contra la responsabilidad civil es un contrato que agota sus efectos entre las partes de la relación negocial, rigiendo a su respecto lo dispuesto por los artículos 1021 y 1022, CCyCN. En cambio, a la estipulación en favor de tercero, universalmente se la examina como hipótesis de extensión de los efectos subjetivos del contrato;

g) El seguro contra la responsabilidad civil se hace operativamente ostensible en el proceso promovido por el damnificado contra el responsable, siempre y cuando haya sido citado en garantía el asegurador de este último. Por el contrario, la estipulación en favor de tercero resulta de una cláusula accesorio que, ineludiblemente, deben acordar estipulante y promitente, sin que ninguno de ellos pueda permanecer oculto al beneficiario;

h) En el seguro contra la responsabilidad civil, el crédito del damnificado tiene privilegio especial sobre la suma asegurada y sus accesorios, con preferencia sobre el asegurado y cualquier acreedor de éste (art. 118 -1, L.S. y art. 241 inc. 6], Ley de Quiebras). Y ello acontece desde la comisión del ilícito (lato sensu). Ello significa que la suma asegurada (asiento del privilegio) deberá destinársela, con carácter preferente, a satisfacer el débito de responsabilidad en que ha incurrido el asegurado. Pero el reconocimiento de un privilegio, no importa la apropiación por el damnificado de la suma asegurada, ni que se altere la naturaleza del contrato. Por caso, su derecho deberá ser declarado judicialmente, y recién entonces el asegurador deberá extinguir su obligación de indemnidad para con el asegurado, depositando en juicio o pagándole directamente al tercero. En cambio, en la estipulación en favor de tercero, en cualquiera de sus aplicaciones, no le viene reconocido al crédito del beneficiario, privilegio alguno. Y constituye un mecanismo que hace que el último se apropie de la ventaja (una vez irrevocable), sin necesidad (ni posibilidad) alguna de convocar al proceso al estipulante;

i) En el seguro contra la responsabilidad civil, el asegurador sólo puede oponer al tercero las excepciones anteriores al siniestro. En la estipulación en favor de tercero, el obligado (promitente) puede oponer al beneficiario todas las excepciones que dispone contra el estipulante, nacidas del contrato en que se concertó la ventaja;

j) En el seguro contra la responsabilidad civil, el incumplimiento por el asegurador de la obligación de indemnidad a que lo someten los artículos 109, 110 y 111 de la Ley de Seguros, faculta al asegurado a promover una pretensión por cumplimiento de la que, salvo el supuesto de un proceso judicial en que el primero se halle citado en garantía y condenado in solidum, se halla excluido el damnificado. Por el contrario, en la estipulación en favor de tercero, la inejecución por el promitente de la obligación

asumida en favor del beneficiario aceptante, consiente una pretensión deducida por éste y contra aquél, su único obligado;

k) En el seguro contra la responsabilidad civil, tal como se halla concebido y legislado en Argentina, no le viene normativamente reconocido al damnificado un derecho propio sobre la suma asegurada. En cambio, en la estipulación en favor de tercero, el derecho propio del beneficiario, por tratarse de un supuesto de extensión de los efectos subjetivos del contrato, se sustenta siempre en un texto legal que así lo reconoce (cfr. por todos, cfr. Stiglitz, Rubén S.: *Derecho de Seguros*, 6ª edic. act. y ampl., La Ley, 2016, t. IV, pp. 37/41).

VII. 4.- De otro costado, la recurrente reprocha que el tribunal aquo le haya negado trascendencia jurídica a los ofrecimientos indemnizatorios realizados por la compañía de seguros, pues a su criterio ello significó reconocer la deuda cuya satisfacción ahora reclama.

Sobre el punto, la Iudex sostuvo: *“Tampoco resulta relevante lo afirmado por la actora en relación a que (...) ‘hubo varios intercambios por mails, y que la empresa asumió su responsabilidad en su calidad de aseguradora y ofreció abonar la suma de pesos cincuenta mil (\$ 50. 000) con más el 15% en concepto de costas, pagaderos en tres cuotas iguales, mensuales y consecutivas’, pues tal como lo ha entendido la doctrina el pago que el asegurador efectúa a favor del tercero, es un efecto accesorio, una consecuencia, naturalmente añadida a su obligación principal, que consiste en mantener indemne el patrimonio asegurado. Si así no fuera, si el asegurado tuviera que anticipar los fondos, quedaría desnaturalizada la noción de indemnidad”* (fs. 308).

La apelante no ha refutado este argumento del tribunal.

En mi opinión, si la damnificada en un accidente de tránsito negocia extrajudicialmente los términos de la indemnización con la aseguradora del interviniente considerado responsable por la colisión vehicular, ello no implica *per sé* que hubiera mediado un reconocimiento de la responsabilidad del asegurado o un supuesto autónomo de asunción de deuda.

Interpretar esa actuación de la aseguradora de la manera pretendida por la apelante importaría tergiversar la regulación legal y contractual del desenvolvimiento de la relación asegurativa. En esa línea, producido el siniestro y denunciada la eventual responsabilidad que le cabría al asegurado, la ley impone una serie de cargas y obligaciones al asegurador, particularmente direccionadas a precisar la situación jurídica de su asegurado (v. g. art. 56), para satisfacer la obligación de mantenerlo indemne, incluso arribando a un acuerdo extrajudicial con el tercero damnificado, sin que ello importe reconocimiento alguno de la responsabilidad civil que por el evento dañoso pueda pesar sobre su asegurado, a tal punto que el sistema legal le reconoce el derecho de subrogarse en los derechos que le corresponde a este último contra un tercero, en razón del siniestro, hasta el monto de la indemnización (art. 80).

A riesgo de ser reiterativo, ya he destacado que el objeto del contrato de seguro de responsabilidad civil es cubrir la integridad patrimonial del asegurado, respecto de cualquier hecho o circunstancia que pueda generar su responsabilidad civil (art. 109).

Esta indemnidad comprometida como contraprestación de la prima recibida, está subordinada al acaecimiento del siniestro producto del evento dañoso previsto en el contrato, de donde se sigue que su ocurrencia constituye per se una posibilidad real de daño para el asegurado, aunque el damnificado demore la exigencia de su resarcimiento.

Por ello la sola producción del siniestro justifica el interés de la aseguradora en neutralizar esa amenaza de daño para su asegurado, para que este último continúe indemne, sin perjuicio del derecho a repetir que la ley le confiere (art. 80).

A la luz de estas premisas, los ofrecimientos realizados por la aseguradora no importaron el reconocimiento del daño reclamado por la actora y de la eventual responsabilidad de su asegurado, sino el cumplimiento mismo de una prestación nuclear emergente del contrato de seguro en pos de ajustar su conducta a ley y el contrato.

Tal circunstancia se desprende incluso de los propios términos en que aquellos

ofrecimientos fueron efectuados. Así, conforme surge del contenido del mail cuya copia luce incorporada a fs. 42 y reconocida a fs. 203 por el emisor empleado de la compañía, la primera propuesta de la aseguradora se expresó cuanto sigue: “... *La comunicación aquí iniciada responde al compromiso de indemnidad patrimonial que detenta esta aseguradora, respecto de su asegurado, propietario y/o conductor del vehículo asegurado, según condiciones de póliza contratada y ley 17.418. Efectuada esta salvedad y sin que la presente signifique reconocimiento de hechos, derecho ni responsabilidad alguna por parte de Seguros Rivadavia Coop. Ltda y/o Mutual Rivadavia de Seguros del Transporte Público de Pasajeros, respecto de nuestro asegurado, propietario y/ o conductor del vehículo amparado, dejando a salvo los derechos de los mismos, le informo que la Cooperativa ha dispuesto ofrecer la suma de \$50.000 en dos cuotas pagaderas a los 30 y 60 días de recibida su conformidad, en cheque con leyenda ‘no a la orden’ + 15% de honorarios*”. En el segundo ofrecimiento, de redacción más sencilla, se indicó “*un nuevo monto de \$ 70.000 pagaderos en dos cuotas a 30 y 60 días de recibida su conformidad + 15 % de honorarios*”.

De lo expuesto se colige que las propuestas de arreglo formalizadas por la aseguradora no significaron el reconocimiento de la responsabilidad atribuida a su asegurado.

En consecuencia, la resistencia de la demandada a la procedencia del presente reclamo judicial no implicó la transgresión del principio de buena fe o la doctrina de los actos propios, sino el legítimo ejercicio del derecho de defensa tendiente a hacer mérito de un obstáculo para el acogimiento de la concreta pretensión resarcitoria promovida en su contra, desde que si la obligación de la aseguradora consiste en cubrir -en cuanto por Derecho corresponda- lo que su asegurado debería a la damnificada por causa del accidente de tránsito, entonces no se le puede hacer extensiva a aquella una condena que no puede dictarse por no haber sido demandado en juicio el eventual responsable.

VIII.1 - La razones expuestas en los acápites que anteceden justifican la desestimación de la pretensión resarcitoria de la Sra. Carolina Reyna, con excepción del segmento relativo al reintegro de ciertos gastos.

En efecto, cuadra recordar en lo que aquí interesa, que el extenso art. 68 de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 , luego de establecer que todo automotor, acoplado o semiacoplado debe estar cubierto por seguro, de acuerdo a las condiciones que fije la autoridad en materia aseguradora, que cubra eventuales daños causados a terceros, transportados o no, prescribe: “...*Los gastos de sanatorio o velatorio de terceros, serán abonados de inmediato por el asegurador, sin perjuicio de los derechos que se pueden hacer valer luego. El acreedor por tales servicios puede subrogarse en el crédito del tercero o sus derechohabientes. Carece de validez la renuncia a un reclamo posterior, hecha con motivo de este pago...*”.

Si bien se mira, los párrafos transcritos de la disposición normativa bajo examen, lejos están de disciplinar un aspecto exclusivamente atinente al “*uso de la vía pública*” y “*la circulación de personas, animales y vehículos terrestres en la vía pública, y a las actividades vinculadas con el transporte, los vehículos, las personas, las concesiones viales, la estructura vial y el medio ambiente, en cuanto fueren con causa del tránsito*” ; antes bien, se adentran directamente a regular el alcance de las obligaciones de las compañías aseguradoras en el supuesto específico del seguro automotor obligatorio, tratándose de una típica cuestión de derecho común cuyo dictado compete al Congreso de la Nación. De allí el silencio que guardan sobre el punto la legislación provincial (cfr. Ley 8.560, art. 106) y municipal (cfr. Ord. Mun. N° 9.981, art. 85).

El dispositivo legal consagra, de tal modo, lo que se ha dado en llamar “*obligación legal autónoma*”, atribuyendo por razones humanitarias a la víctima de un accidente de tránsito (o sus derechohabientes) una acción directa para reclamar los “*gastos de sanatorio y de sepelio*” a cualquiera de las aseguradoras involucradas en el evento dañoso independientemente de la responsabilidad que le quepa a su asegurado, pudiendo luego esta repetir contra aquella que tenga la cobertura del verdadero responsable del daño (cfr.

Piedecabras, Miguel A.: *Seguro Obligatorio Automotor*, Rubinzal Culzoni, 2010, pp. 225 y ss; Lorences, Valentín Héctor: *Derecho de Tránsito*, Astrea, 2018, p. 250).

Se trata de una obligación de la aseguradora que no emerge de un vínculo contractual, sino de la ley, y apunta a brindar a la víctima una prestación de urgencia por los gastos de atención médica o de sepelio en su caso, es decir, a dar *“una respuesta inmediata desde un sistema económico-financiero y sin perjuicio de que luego los operadores del sistema puedan repetir lo pagado, ya sea del responsable civilmente o de la seguridad social, o lo absorban directamente porque no existe posibilidad de repetición”* (Piedecabras, Miguel A.: *Seguro Obligatorio Automotor*, Rubinzal Culzoni, 2010, p. 230).

A la fecha de ocurrencia del accidente (**10/ 11/ 2015**), se encontraba vigente la Resolución 39.327 / 2015 dictada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, cuyo Anexo I (“TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS”), Cláusula 1.2 prescribía: *“Se cubre la OBLIGACIÓN LEGAL AUTONOMA por los siguientes conceptos: 1. Gastos Sanatoriales por persona hasta PESOS QUINCE MIL (\$ 15. 000); 2. Gastos de Sepelios por persona hasta PESOS OCHO MIL (\$ 8.000). Los Gastos Sanatoriales y de Sepelio, serán abonados por la Aseguradora al tercero damnificado, a sus derechohabientes o al acreedor subrogante dentro del plazo máximo de CINCO (5) días contados a partir de la acreditación del derecho al reclamo respectivo, al que no podrá oponérsele ninguna defensa sustentada en la falta de responsabilidad del Asegurado respecto del daño. Los pagos que efectúe la Aseguradora por estos conceptos, serán considerados como realizados por un tercero con subrogación en los derechos del acreedor y no importarán asunción de responsabilidad alguna frente al damnificado. El Asegurador tendrá derecho a ejercer la subrogación contra quien resulte responsable. La cobertura comprende la totalidad de los reclamos que se efectúen ante la Aseguradora hasta el límite de PESOS QUINCE MIL (\$15. 000) por persona damnificada”*. Luego, por Resolución 39927/2016 (B.O.: 18/07/2016) aquellos montos se duplicaron.

VIII.2 - En torno a la aplicación de las normas antes mencionadas, debe decirse que la ocurrencia material del accidente de marras en la fecha señalada en la demanda (**10/ 11/ 2015**) se encuentra acreditada en la causa, a partir del reconocimiento del intercambio epistolar habido entre las partes y las declaraciones testimoniales brindadas por el chofer del colectivo involucrado, Sr. Sergio Gabriel Meisel (cfr. fs. 183/ 183vta) y por el apoderado de la empresa Emprendimientos S.R.L. (FONO BUS) (cfr. 201/201 vta).

Ese mismo día, el Dr. Diego José Cuellar Hurtado, médico residente del Sanatorio Allende, certificó la atención médica recibida por la actora en los siguientes términos: *“Dejo constancia que la paciente Reyna, Carolina, DNI 26.481.760, fue atendida en la consulta traumatológica el día de hoy por traumatismo directo de codo izquierdo en accidente múltiple de autos, examen físico: edema con limitación marcada a la movilidad de codo izquierdo, dolor a la palpación de gemelo interno con ligero edema de pierna derecha, con movilidad conservada, en RX se evidencia fractura supracondílea de codo izquierdo. Se realiza férula de yeso braquial, control en 48 hs.”* (fs. 50 y 215).

Dos días después (**12/11/ 2015**), la Sra. Carolina Reyna fue sometida a cirugía por “fractura de la epifisis inferior del humero izquierdo” y osteosíntesis mediante colocación de placa y tornillos (fs. 55 y 220) practicada por el Dr. Christian Antonio Allende Norez, recibiendo el alta al día siguiente con cita para control por consultorio (fs. 54).

Con fecha **06/ 05/2016**, el mencionado galeno certifica la condición de la Sra. Reyna como sigue: *“Que presenta fractura supra condílea de húmero, tratada con osteosíntesis, que necesita extracción quirúrgica del material de osteosíntesis, más neurolisis cubital, bajo anestesia y con un día de internación”*. El citado profesional refiere en su declaración testimonial que debió realizar una segunda operación en el mes de julio de 2016 (cfr. fs. 220).

Estos extremos permiten vincular causalmente al accidente con los gastos médicos reclamados en la demanda, a saber: Placa de reconstrucción: \$6.000 (cfr. fs. 18, 55 y 220); Gastos de farmacia de fecha **10/11/2015** (\$ 129,42 y \$158,40); cfr. fs. 19vta);

13/11/2015 (\$110,05; cfr. fs. 19vta); **20/11/2015** (\$43,87; cfr. fs. 19); **18/12/2015** (\$315; cfr. fs. 35) y **21/12/2015** (\$529,33; cfr. fs. 35).

De tal modo, esas puntuales erogaciones reclamadas (cfr. fs. 7vta/ 9) encuadran en el concepto de gastos de sanatorio, atento a que se devengaron en razón de “*los procedimientos médicos para la curación o atención del tercero dañado*” a causa del accidente (Piedecabras, Miguel A.: *Seguro Obligatorio Automotor*, Rubinzal Culzoni, 2010, p. 227).

VIII.3 - No desconozco que a fs. 154, compareció el Dr. Agustín Gorrochategui apoderado de la demandada SEGUROS RIVADAVIA, invocó también la representación de MUTUAL RIVADAVIA DE SEGUROS DEL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS y agregó copia de la denuncia del siniestro bajo la lupa y de la póliza contratada, señalando al mismo tiempo que conforme lo adelantado al contestar la demanda, la unidad de transporte público denunciada por la parte actora no se encontraba asegurada en SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOP. LTDA sino en la MUTUAL referenciada.

Cabe remarcar que en el escrito de contestación de la demanda, SEGUROS RIVADAVIA adujo, en primer término la improponibilidad objetiva de la demanda, con fundamento en la inexistencia de vínculo jurídico entre la actora y la demandada, que el reclamo había sido formulado en violación a la ley de seguros y presuponía reconocerle a la accionante la calidad de damnificada en un accidente cuya existencia no había sido probada y la falta de acción directa en contra de la demandada. Luego opuso la excepción de falta de acción, reiterando que la víctima del supuesto accidente de tránsito carecía de acción directa en contra de la aseguradora. Seguidamente, denunció un “*error en la denominación de la aseguradora*”, afirmando que “*la aseguradora que cubre el supuesto siniestro motivo de autos es ‘MUTUAL RIVADAVIA DE SEGUROS DEL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS’ y no la Cooperativa*” demandada (fs. 108vta).

De ello se infiere que esta última no opuso como obstáculo al progreso de la demanda que se trataba de una persona jurídica distinta de la que debía haber sido citada en este proceso en calidad de aseguradora.

Más aún, en el sitio web de SEGUROS RIVADAVIA, la solapa “*Transporte de pasajeros*” redirige a una nueva ventana (<http://www.mutualrivadavia.com/transporte/>; fecha de consulta: 06/11 /2018), donde puede leerse lo siguiente: “*En el marco de la Resolución General de la Superintendencia de Seguros de la Nación N° 25.429 de noviembre de 1997, Seguros Rivadavia consolidó el nacimiento de la Mutual Rivadavia de Seguros del Transporte Público de Pasajeros... Ambas empresas, bajo un modelo de conducción unificada, conforman el grupo que hoy se denomina Seguros Rivadavia*”.

Si bien por carta documento remitida por el apoderado de Emprendimientos S.R. L. la actora había tomado conocimiento de que la empresa propietaria del colectivo había denunciado el siniestro ante la aseguradora MUTUAL RIVADAVIA DE SEGUROS DEL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS (cfr. fs. 162), lo cierto es que el reclamo extrajudicial se presentó ante la aseguradora demandada (cfr. fs. 47) y con ella continuaron las negociaciones que a la postre fracasaron, según dan cuenta las impresiones de los mail intercambiados entre la apoderada de la parte actora y los Sres. Mauricio Petrei y Gustavo Such Monlezún, estos últimos empleados en relación de dependencia de la empresa accionada (cfr. fs. 202/203vta).

Haciendo mérito de estas circunstancias, cabe concluir que SEGUROS RIVADAVIA debe reintegrar a la actora los gastos de sanatorio bajo examen, en los términos del art. 68 de la ley 24. 449, de modo que la condena procede por la suma de pesos siete mil doscientos ochenta y seis con siete centavos (\$7.286, 07), con más intereses moratorios conforme a la aplicación de la Tasa Pasiva que publica el B.C.R. A. con más el 2% nominal mensual, desde la fecha de cada desembolso y hasta el día del efectivo pago (art. 1.747 CCyCN).

IX.- Costas.- El éxito parcial de la apelación planteada sobre el fondo del asunto litigioso obliga a readecuar la distribución de los gastos causídicos - y la regulación de honorarios- dispuesta en primera instancia, ello aunque no fuera un punto que hubiera

sido sometido a la competencia de este Tribunal de Alzada (cfr. fs. TSJ, Sala CyC, “Godino de Ditrich Amelia Teresita - Quiebra Pedida - Recurso Directo (Expte. G-13/04)”, Auto N° 366/07, 03/ 12/2007; íd., “Arcor SAIC y otros c/ Rubén D. Duchosal SA y otros - Ordinario - Recurso de casación”, Sent. N° 124, 07/10/2008).

Sabido es que la regla directriz en materia de costas dicta su imposición al vencido, siendo la excepción la exoneración, total o parcial, de este último, la que además debe decidirse de modo fundado.

Siguiendo tal hermenéutica, el legislador local ha receptado expresamente, tal solución como principio general, al disponer en el art. 130 del Código de rito: *“La parte vencida será condenada al pago de las costas del juicio, aunque la contraria no lo haya solicitado, a menos que el tribunal encontrare mérito para eximirla total o parcialmente, debiendo, en este caso, fundar la resolución”*.

El principio objetivo de la derrota impone, como actividad esclarecedora del problema de la imposición de costas, reparar en la dirección que han tenido las pretensiones esgrimidas por las partes, y confrontarlas con el resultado final de la controversia, para así conocer cuál de ellas, y en qué proporción, ha tenido éxito en el proceso.

En tal orden de ideas, el Tribunal Superior de Justicia ha señalado que *“... El precepto del art. 130 del CPC establece como principio general que las costas deben ser impuestas al ‘vencido’ , debiendo entenderse a este último como aquel que ha sido ‘...derrotado por completo’ (Cfr. Alsina, Hugo: “Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial”, segunda edición, Buenos Aires, 1961, Ed. E., T. IV, pág. 546). En sentido concordante señala Lino Enrique Palacio que, por parte vencida debe entenderse a ‘ aquélla que obtiene un pronunciamiento judicial totalmente adverso a la posición jurídica que asumió en el proceso’ , agregando que el actor es vencido ‘ cuando su pretensión es rechazada en su integridad’ y que el demandado es vencido ‘ en el supuesto de que su oposición corre la misma suerte o de que, habiéndose verificado su incomparecencia (rebeldía) o falta de réplica, la sentencia actúe la pretensión del actor ’ (Cfr. autor citado: “Derecho Procesal Civil”, Buenos Aires, Ed. A.P., 1970, T. IV, pág. 369. Ninguna duda ofrece entonces el alcance que cabe asignar al criterio objetivo del vencimiento consagrado en el art. 130 del CPCC: las costas deben ser soportadas por aquella parte cuya pretensión no ha encontrado tutela alguna en el proveimiento del juzgador...”. “Distinto será, en cambio, el reparto cuando - como en el caso- no haya existido un triunfo y correlativo fracaso total. Por ello es que, en los supuestos - como el de marras- en que se hace lugar parcialmente a la demanda o al recurso, debe reputarse -en principio- que el vencimiento es ‘parcial y mutuo’, ya que ninguna de las partes ha logrado ver satisfechos íntegramente sus planteos judiciales. La doctrina ha acompañado esta solución señalando que ‘Si se hace lugar parcialmente a la demanda, ello implica un rechazo parcial de la oposición en aquello en que se ha acogido la demanda, y, a la inversa, existe acogimiento parcial de la oposición del demandado en aquello en que se rechaza parcialmente la demanda, en tal caso hay vencimiento parcial y mutuo de ambas partes’ (Loutayf Ranea, Roberto G.: ‘Condena en costas en el proceso civil’, Bs. As ., Ed. A., 1998, pág. 123)” (TSJ, Sala CyC in re: “Sosa, Ramón Rómulo y otro e/ Aguas Cordobesas - Ordinario - Recurso de casación”, Sent. N° 169, 10/9/09, Zeus Cba. N° 366, p. 537; en igual sentido: ibíd., “Coniferal SA e/ Huespe, Elías y otro - Ordinario - Recurso de casación”, Sent. N° 42 , 19/ 4/05 (casación. en virtud del inc. 3 del art. 383 CPC); “Sucesores de Alejandro Vicente Bermúdez e/ Antonio Miguel Burgos A. - Ordinario - Recurso directo”, Sent. N° 49, 30/07/07, Zeus Cba. N° 274, p. 671).*

En ese sendero, cabe poner de relieve que en el caso sub lite la procedencia parcial de la demanda importa vencimientos recíprocos, ya que tanto la actora como el demandado verán -si mi voto es compartido- desestimadas parcialmente su pretensión y defensa, respectivamente.

Cobra entonces aplicación el precepto del art. 132 del CP CC que dispone expresamente que *“las costas se impondrán prudencialmente en relación al éxito*

obtenido” por cada una de las partes.

La solución propugnada no implica desconocer que una correcta aplicación de dicho precepto legal no impone, frente a la procedencia parcial de la demanda, un obligado cálculo de proporción matemática entre lo demandado y la condena.

Por el contrario, el art. 132 del código de rito brinda dos parámetros o directrices de orientación en la labor judicial de distribuir de las costas: uno de naturaleza objetiva: el éxito obtenido en el reclamo; y otro de índole subjetiva: la prudente interpretación judicial de los hechos que sustentan ese diseño de asignación.

Un primer factor que debe necesariamente tenerse en cuenta, es la pretensión deducida en la demanda. Si el quantum de la misma fue condicionado a “lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse” o si la fijación del rubro en cuestión dependiese exclusivamente del arbitrio judicial (como ocurre con el daño moral), va de suyo que si la resolución determina un monto menor al pretendido, no puede considerarse que medió exceso en el reclamo, y no es dable asignarle valía a la diferencia entre lo pretendido y lo acordado. Salvo claro está, que mediare plus petición inexcusable, o una caprichosa indeterminación original del accionante. Un segundo elemento que debe gobernar la prudente interpretación judicial estriba en analizar con detenimiento el “éxito” y el correlativo “fracaso” de ambas partes fijando su incidencia en la imposición de costas. Ello así, pues no es lo mismo que un ítem resarcitorio se rechace en su totalidad, a que se admita por un monto inferior al pretendido por la víctima. Incluso en este último supuesto, corresponde verificar si la demasía en la petición pudo evitarse. Es obvio que el primer supuesto constituye un factor adverso al actor, que legitima una distribución equitativa de las costas con el demandado. Desde otro ángulo, también debe ponderarse la actitud procesal asumida por la víctima luego de precisada, de conformidad a la prueba rendida, una eventual demasía del valor reclamado.

Es criterio del cimero Tribunal local que pronunciarse “*prudencialmente en relación con el éxito obtenido*” requiere efectuar una evaluación del resultado del pleito que no se agota en una ecuación aritmética. Así, por ejemplo, resulta legítimo priorizar como elemento primordial del “vencimiento” el desenlace del pleito sobre los extremos condicionantes del derecho invocado, más que sobre la mera cuantificación del crédito reclamado; o bien atribuir mayor significado a las cuestiones respecto de las cuales más intenso ha sido el debate y el consecuente desgaste jurisdiccional; o, en función de otros criterios razonables, cargar a uno u otro de los litigantes con un porcentaje de las costas no necesariamente igual a la medida en que la demanda ha prosperado. Ello permite que la prudencia del Tribunal -expresamente aludida en la norma- altere el resultado numérico de comparar el monto demandado con la condena (TSJ, “Ponce de León, Ernesto Daniel C/ El Hogar Obrero Cooperativa de Consumo Edificación y Crédito Limitada - Recurso De Casación”, Sent. N° 130, 04/09/2013).

No obsta a lo expuesto el carácter resarcitorio de las costas, pues ostentan esa eficacia en toda clase de procesos sin distinción. En efecto, la condena no justifica per se imponer todas las costas al demandado, sino atendiendo al alcance en que se dicta, pues sólo hay triunfo del actor en la extensión acogida del objeto que pretendió. Una postura contraria resultaría más difícil de sostener cuanto mayor sea la victoria parcial del demandado a quien se le atribuye responsabilidad, por cuanto se lo obliga a cargar con las costas respecto de la porción por la que resultó victorioso, lo que implica una injusticia, ya que también él debe ser resarcido por los gastos necesarios para su defensa en la porción que resultó legítima.

Está claro que el criterio distributivo propiciado puede conducir a que la deuda por costas absorba total o parcialmente -e incluso supere- la indemnización a que tenía derecho el actor. Pero esta circunstancia, de presentarse, derivaría de la inconducta procesal del reclamante al formular un planteo no ajustado a derecho o exagerado que termina siendo declarado improcedente o por incurrir en negligencia probatoria.

Con arreglo a tales pautas, debe ponderarse que la resistencia opuesta por la aseguradora demandada fue parcialmente legítima, en tanto si bien llevaba razón en

oponerse al reclamo formulado en su contra porque ninguna condena fundada en la ley de seguros se le podía hacer extensiva por no haber sido demandado su asegurado a quien debe mantener indemne; no podía desconocer su obligación legal de abonar a la actora damnificada los gastos de sanatorios prescriptos por la ley 24.449. Ese incumplimiento legal relevado, se erigía, ciertamente, en un serio motivo para efectuar el reclamo extrajudicial y, ante el fracaso de dicha gestión, el inicio del presente pleito a fin de obtener el reintegro de tales erogaciones.

Por otro lado, la pretensión de la actora también ha sido parcialmente legítima, por cuanto si bien le asistía el derecho a accionar directamente en contra de la compañía aseguradora para recuperar el monto de los gastos de sanatorio abonados, prescindiendo de la intervención del presunto responsable asegurado; en cambio, la integración de la litis con este último resultaba necesaria para superar el acotado alcance de la acción directa que la ley le reconocía y obtener la mayor satisfacción posible de su reclamo total, pero en el caso, omitió demandar, sin alegar y probar razón valedera alguna, al sindicato como autor del hecho dañoso respecto de quien la compañía había asumido la obligación de indemnidad patrimonial.

Por todo lo expuesto, estimo justo y razonable imponer las costas de ambas instancias en un sesenta por ciento (60%) a cargo de la demandada y el restante cuarenta por ciento (40%) a cargo de la actora.

Corresponde dejar sin efecto las regulaciones de honorarios de los letrados intervinientes por las tareas desarrolladas en primera instancia, las que deberán practicarse nuevamente con ajuste a lo aquí resuelto.

En virtud de lo dispuesto por los arts. 26, 29, 36 y 40 del Código Arancelario, deben regularse los honorarios de los Dres. Julio I. Altamira Gigena y Carolina Altamira, en conjunto y proporción de ley; y del Dr. Agustín Gorrochategui, por la labor desplegada en esta Sede, en el treinta y cinco por ciento (35%) del punto medio de la escala del art. 36 de dicha ley, sin perjuicio del mínimo legal, con más el porcentaje correspondiente en concepto de IVA por revestir la condición de responsables inscriptos.

Así dejo expresado mi voto.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. VOCAL DR. LEONARDO C. GONZÁLEZ ZAMAR, DIJO:

Adhiero a lo propiciado por el Dr. Guillermo P. B. Tinti, expidiéndome en idéntico sentido.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. VOCAL DR. JULIO C. SANCHEZ TORRES, DIJO:

Adhiero a las conclusiones a las que arriba el Sr. Vocal preopinante, votando en consecuencia en idéntico sentido a la cuestión planteada.

A LA SEGUNDA CUESTION EL SEÑOR VOCAL DOCTOR GUILLERMO P. TINTI, DIJO:

A mérito de la respuesta dada a la primera cuestión, corresponde: 1) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, modificar parcialmente la sentencia número ciento setenta y cuatro de fecha diecinueve de junio de dos mil dieciocho y condenar SEGUROS RIVADAVIA COOP. LTDA a abonar a la Sra. Carolina Reyna, dentro del término de diez días y bajo apercibimiento, suma de pesos siete mil doscientos ochenta y seis con siete centavos (\$7.286, 07) , con más los intereses fijados en el Considerando respectivo; 2) Imponer las costas de ambas instancias en un sesenta por ciento (60 %) a cargo de la demandada y el restante cuarenta por cien to (40%) a cargo de la actora; 3) Dejar sin efecto las regulaciones de honorarios de los letrados intervinientes por las tareas desarrolladas en primera instancia, las que deberán practicarse nuevamente con ajuste a lo aquí resuelto ; 4) En virtud de lo dispuesto por los arts. 26, 29, 36 y 40 del Código Arancelario, regular los honorarios de los Dres. Julio I. Altamira Gigena y Carolina Altamira, en conjunto y proporción de ley; y del Dr. Agustín Gorrochategui, por la labor desplegada en esta Sede, en el treinta y cinco por ciento (35%) del punto medio de la escala del art. 36 de dicha ley, sin perjuicio del mínimo

legal, con más el porcentaje correspondiente en concepto de IVA por revestir la condición de responsables inscriptos.

Así voto.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR VOCAL DR. LEONARDO C. GONZÁLEZ ZAMAR, DIJO:

Adhiero en un todo a las conclusiones arribadas por el Sr. Vocal de primer voto, Dr. Guillermo P. B. Tinti, votando en consecuencia en el mismo sentido a la cuestión planteada.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. VOCAL DR. JULIO C. SANCHEZ TORRES, DIJO:

Por considerar correctos los fundamentos expuestos por el Sr. Vocal preopinante, adhiero en un todo a los mismos.

Por todo lo expuesto, el Tribunal

RESUELVE:

1) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, modificar parcialmente la sentencia número ciento setenta y cuatro de fecha diecinueve de junio de dos mil dieciocho y condenar SEGUROS RIVADAVIA COOP. LTDA a abonar a la Sra. Carolina Reyna, dentro del término de diez días y bajo apercibimiento, suma de pesos siete mil doscientos ochenta y seis con siete centavos (\$7.286,07), con más los intereses fijados en el Considerando respectivo.

2) Imponer las costas de ambas instancias en un sesenta por ciento (60%) a cargo de la demandada y el restante cuarenta por ciento (40%) a cargo de la actora.

3) Dejar sin efecto las regulaciones de honorarios de los letrados intervinientes por las tareas desarrolladas en primera instancia, las que deberán practicarse nuevamente con ajuste a lo aquí resuelto.

4) Regular los honorarios de los Dres. Julio I. Altamira Gigena y Carolina Altamira, en conjunto y proporción de ley; y del Dr. Agustín Gorrochategui, por la labor desplegada en esta Sede, en el treinta y cinco por ciento (35%) del punto medio de la escala del art. 36 de dicha ley, sin perjuicio del mínimo legal, con más el porcentaje correspondiente en concepto de IVA por revestir la condición de responsables inscriptos.

Protocolícese y bajen.